

1500078-03.2022.8.26.0210

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDERSON VALENTE

Comarca: Guaíra

Foro: Foro de Guaíra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... é equiparado aos hediondos.

O crime de tráfico de entorpecentes é equiparado aos delitos hediondos, portanto os mais graves dentre os elencados no Código Penal e em Leis Especiais.

Logo, soa, no mínimo, incongruente a fixação de regime diverso do fechado para o crime de tráfico de drogas.

Há, como é de sabença, crimes graves, mas que não são tidos como hediondos, como, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaíra

Foro de Guaíra

1ª Vara

Av. 17, 414, Guaíra - SP - cep 14790-000

1500078-03.2022.8.26.0210 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500078-03.2022.8.26.0210

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

APARECIDO DONISÉTI LEITE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON VALENTE

Vistos.

I. APARECIDO DONISETI LEITE, qualificado a fls. 14, foi denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 1º de

fevereiro de 2022, por volta das 19h, na Rua 6 nº 1.395, Bairro Bom Jesus, nesta cidade e Comarca, teria em depósito, com finalidade de traficância e entrega ao consumo de terceiros, três porções de crack, com peso líquido de 961,67 g, bem como cento e vinte e quatro porções de crack, com peso líquido de 30,18 g, além de outra porção do mesmo entorpecente, com peso líquido de 17,62 g, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

É da denúncia que “na data dos fatos, policiais militares receberam notícia de que o denunciado, indivíduo conhecido pelo tráfico de drogas, teria recebido grande quantidade de entorpecentes. Diante da informação, dirigiram-se até a residência dele e, após breve campana, observaram uma movimentação incomum de pessoas, típica de possíveis usuários de entorpecentes.

Diante das circunstâncias, os policiais resolveram ingressar no imóvel e surpreenderam o denunciado sentado na mesa da cozinha fracionando e embalando porções de crack.

Sobre a mesa, os policiais apreenderam 124 porções de crack já embaladas em papel alumínio, além de 50 pedriscos de crack sem embalagem, bem como R\$ 245,00 em dinheiro trocado, uma balança de precisão, um rolo de papel alumínio, uma caixinha com quatro lâminas de barbear e um telefone celular. Ainda, no forro do imóvel, os policiais apreenderam mais três pedras grandes de crack, totalizando mais de um quilo de entorpecente.”.

A denúncia de fls. 110/111 foi recebida em 18 de fevereiro de 2022 (fls. 113), sendo o Réu citado (fls. 122), apresentando defesa preliminar em fls. 131/132 rejeitada em fls. 135/137. Durante a instrução foi colhida prova oral e interrogado o Réu (cf. mídia digital em fls. 166).

Em memoriais, o ilustre representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia (fls. 164/165).

A douta Defesa, por seu turno, requereu a improcedência da ação, alegando a ocorrência de flagrante forjado, que resultaria em crime impossível, pretendendo a improcedência da ação penal com base no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal (fls. 177/186).

É o relatório.

II. Fundamento e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está estampada no auto de prisão em flagrante de fls. 01/06, no boletim de ocorrência de fls. 07/09, auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, auto de constatação preliminar de fls. 38/40, comprovante de depósito de fls. 97, nos laudos periciais de fls. 106/108 e 159/163, pelo laudo de exame químico-toxicológico a fls. 126/128, além da prova oral colhida durante a instrução.

A autoria é certa contra o Réu que na fase inquisitorial optou pelo silêncio (fls. 05), ao passo que em Juízo negou o teor da acusação, sustentando que depois de saiu da prisão passou a usar muita droga e sua casa era frequentada por vários usuários. Porém, a droga localizada não lhe pertencia, não sabendo de quem seria, relatando que no dia os policiais ingressaram no local e encontraram o entorpecente, mas não estava fracionando drogas naquele momento, alegando, ademais, que o dinheiro era fruto de seu trabalho como servente de pedreiro.

Sua versão não convence e restou isolada nos autos, sendo que, caso verdadeira, faria prova de suas alegações, ônus que lhe competia, com fundamento no artigo 156 do Código de Processo Penal.

De início deve ser destacado que, como se sabe, o direito ao silêncio é cláusula constitucionalmente assegurada, mas não é crível se acreditar que aquele que tenha sido injustamente preso pela prática de um crime assemelhado ao hediondo tivesse a frieza de manter-se calado para somente em Juízo informar a prisão equivocada, demonstrando que o Réu nada tinha a indicar em sua defesa no momento de sua prisão, cabendo salientar brilhante excerto de acórdão do E. Tribunal de Justiça Bandeirante, pois o Réu “assumiu comprometedora, ainda que legalmente tolerada, postura silente, quando é certo que aquele que se vê injustamente acusado, trata, logo, de anunciar a injustiça da acusação, se convidado a falar sobre ela” (TJSP, Ap. 990.09.059887-5, 3ª C.D.Crim., Rel. Des. Geraldo Wohlers, j. 04.08.2009).

O policial militar Deivid, em depoimento judicial, relatou que há muito vinham monitorando o Acusado, que era apontado por vários usuários como traficante e depois que ele saiu da prisão aumentou o número de viciados nas imediações. No dia, foram informados que ele havia recebido grande quantidade de crack, dirigindo-se até sua residência, ingressaram e o viram sentado na cozinha, fracionando grande quantidade de crack, embalando a droga em papel alumínio, o que era um diferencial de sua traficância, entendida pelos usuários como zelo. Encontraram dinheiro e telefone celular, bem como mais uma grande quantidade de crack escondida no forro em três porções, sendo possível sua localização devido ao forte odor que exalava. No mais, disse que é o Réu conhecido pela traficância, que vários usuários ficavam do lado de fora de sua casa, a qual tem alguns furos que permitem que entregue a droga sem que mantenha contato físico com os compradores, tendo o Acusado confirmado que a droga era dele, não aparentando estar entorpecido. Em linhas gerais, este foi o teor do depoimento do policial militar Michel, que ainda declarou que na data dos fatos ingressaram no local porque viram vários usuários de drogas.

A conduta do Acusado, pois, indica que no dia, horário e local apontados na denúncia tinha em depósito substância entorpecente para fins de traficância. A isso se chega com a prova coligida aos autos, notadamente a grande quantidade de crack encontrada na residência do Réu (local onde ele mora sozinho, segundo por ele confirmado) o dinheiro sem indicação de origem (já que não conseguiu sequer dizer onde estaria desempenhando seu trabalho de servente), não demonstrando deter ocupação lícita, além de não estar sob efeito de drogas e, ademais, ser conhecido dos meios policiais pela traficância, confirmando esse fato aos policiais quando preso. Tais condutas apontam que o Réu utilizava o entorpecente apreendido consigo para fins de mercantilização, consoante se extrai do artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 11.343, de 23.08.2006.

Nem se olvide pelo fato de a Acusação se embasar somente no depoimento prestado por policiais, que é válido e está em consonância com as demais provas, sem existência de qualquer indicativo de sua imprestabilidade, não podendo ser descartados, notadamente porque o Réu, conforme sobredito, não ofertou qualquer resistência ao depoimento deles.

A condição funcional não os torna suspeitos, valendo, outrossim, o princípio de presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados. Nesse diapasão, “Com relação aos depoimentos de policiais, os entendimentos jurisprudenciais têm convergido na direção de que são eles válidos e aptos ao suporte de uma condenação, pois aqueles agentes da autoridade prestam os seus esclarecimentos sob o compromisso da verdade como qualquer testemunha e as suas narrativas devem ser entendidas como verdadeiras até a produção de provas em contrário, com demonstração da falácia, recaindo o ônus da produção destas na esfera da defesa, situação que incorreu nos autos.

Pequenas divergências encontradas no cotejo dos depoimentos prestados pelos policiais, sem atingirem o âmago da questão, devem ser desprezadas, posto que podem ser produto do posicionamento dos mesmos quando da diligência efetuada e das tarefas de cada um deles naquele momento, além do entrelaçamento de situações

diante do elevado número de ocorrências que tais policiais atendem no dia a dia, sem o comprometimento daquilo que narraram" (TJSP, Ap. 990.08.168537-0, 10ª C.D.Crim., Rel. Des. Otávio Henrique, j. 16.04.2009).

Some-se a isso que a balança apreendida com o Réu, submetida a perícia, teve identificado resquício de cocaína (fls. 106/108).

De outra forma, não há que se falar em flagrante forjado, quando o Acusado acabou por ser preso em flagrante típico, junto com a substância entorpecente, afastando-se a tese da douta Defesa, não podendo se falar, conseqüentemente, em crime impossível, porque consumada a prática criminosa.

Assim, tem-se a declaração isolada do Réu dada em Juízo que, por motivos óbvios, possui intenção de se isentar das penas da narcotraficância e, de outro lado, o depoimento uníssono dos policiais militares, agentes públicos que contaram com detalhes a prisão do Réu, nada sendo levantado e muito menos comprovado contra eles, de forma que viesse a colocar em xeque seus depoimentos.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do acusado ou extingam a punibilidade. Sendo assim, reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

O Acusado ostenta antecedentes que, contudo, não podem ser empregados como forma de majoração da pena nesta fase para não se incorrer em bis in idem com a reincidência porque se tratam dos mesmos processos. Nada obstante, é o caso de majorar sua pena-base, considerando a grande quantidade de crack apreendida, para os padrões desta cidade, sendo uma das mais viciantes e letais drogas existentes, abundância esta que evidencia o claro indicativo de que o comércio clandestino seria abastecido por razoável período, razão pela qual, atendendo aos critérios dos artigos 59 e 60 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06, promovo o aumento da pena-base em ½ (metade) e a fixo inicialmente em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no menor patamar, à míngua da comprovação de suas condições financeiras.

Na segunda fase aumento sua pena em 1/3 (um terço) em razão da multirreincidência em crime doloso (cf. fls. 43, autos nº 0002372-15.2016.8.26.0210; fls. 43/44, processo nº 0002438-92.2016.8.26.0210; fls. 45, processo nº 0004912-46.2010.8.26.0210), sendo que as apontadas em fls. 43 e 45 são condenações passadas em julgado por tráfico de drogas, demonstrando persistência de alta gravidade neste crime, atingindo o patamar de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1.000 (um mil) dias-multa.

O Acusado não faz jus à causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, uma vez que a forma como se desenhou os fatos, sendo ele, portador de péssimos antecedentes e duplamente reincidente específico, conhecido pela traficância e encontrada em seu poder grande quantidade de crack, vem a demonstrar que se dedica, indubitavelmente, à atividade criminosa do tráfico de drogas, tanto que não demonstrou possuir ocupação lícita.

Nesse diapasão: "Para redução da pena, essencial que o réu seja 'primário', apresente 'bons antecedentes', comprove que 'não se dedique às atividades criminosas', assim como, 'nem integre organização criminosa'. Evidente que essa causa de redução da pena está reservada àquele que age por um impulso, um desvio, em situação isolada no tráfico de drogas. E mais, os parâmetros para a graduação da redução (1/6 a 2/3) devem ser objetivos e extraídos das diversas circunstâncias que envolvam o caso concreto, podendo variar dentro do seu campo de incidência. Essa causa de redução da pena deve incidir na excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu, e não de uma contumácia,

estilo, repetição de fato análogo, de uma rotina de proceder.

Ao julgador compete a análise do impulso, do fator determinante da conduta objetivamente tratada, que lhe permita concluir tratar-se mesmo de caso de um criminoso meramente ocasional, ou mesmo, se vem tomando aquela conduta como estilo de vida, para que possa, não apenas determinar a gradação da redução da pena, como até mesmo o total afastamento da causa de redução" (TJSP, Ap. 0003548-97.2014.8.26.0210, 3ª C.D.Crim., Rel. Des. Luiz Antonio Cardoso, j. 30.07.2019).

O regime de cumprimento de pena adequado, por se tratar de crime equiparado ao hediondo, é o inicial fechado. Nesse panorama: "O regime prisional inicial fechado foi fixado com absoluto acerto, não só por previsão legal artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07 como, também, pela gravidade do crime, de catastróficas consequências à saúde pública, e responsável, também, pela desagregação familiar e social. Tanto é que o delito é equiparado aos hediondos.

O crime de tráfico de entorpecentes é equiparado aos delitos hediondos, portanto os mais graves dentre os elencados no Código Penal e em Leis Especiais.

Logo, soa, no mínimo, incongruente a fixação de regime diverso do fechado para o crime de tráfico de drogas.

Há, como é de sabença, crimes graves, mas que não são tidos como hediondos, como, por exemplo, o de roubo agravado, o de homicídio simples, dentre outros. Mesmo o tráfico de drogas, considerado o § 4º, do artigo 33 da respectiva Lei Especial, é, sem dúvida, crime grave.

Mas há os considerados hediondos.

Hediondo quer significar horrendo, gravíssimo, repulsivo, absolutamente intolerável.

Ora, sendo assim, como aplicar-se para um crime hediondo, como o tráfico de entorpecentes, regime que não o inicial fechado?

O traficante, perante a lei penal tal como está em vigor, é tido como um pária da sociedade, que destrói, não só a saúde das pessoas, especialmente a dos jovens, deixando muitos deles incapacitados para estudar ou mesmo trabalhar, pois é sabido que a cocaína e o 'crack', por exemplo, além de causarem dependência, destroem os neurônios, como ainda arrasam os patrimônios das famílias, com gastos desmesurados com tratamentos e internações, e o que é pior: com mínimas chances de recuperação. Bem por isso que se trata de crime hediondo.

A sociedade não tolera o traficante, não podendo o Poder Judiciário fazer ouvidos moucos ao clamor social.

O legislador, com a edição da Lei nº 11.343/06, passou a punir o tráfico de forma mais severa exatamente porque o Poder Legislativo percebeu, sentiu que o tecido social estava se esgarçando cada vez mais e que os valores deveriam ser preservados.

Uma sociedade repleta de viciados e dependentes é uma sociedade que caminha a passos largos para sua própria destruição com o prejuízo de todos, menos dos traficantes que, com o dinheiro e patrimônio amealhados de forma criminosa, poderão deixar o País e mudarem-se para outros lugares, onde, com certeza, passarão a destroçar outras sociedades, outras inúmeras famílias.

Em suma, a sociedade e o Brasil como um todo é o que menos os preocupa" (TJSP, Ap. 0000555-39.2016.8.26.0557, 15ª C.D.Públ., Rel. Des. Poças Leitão, j. 01.02.2018).

Por outro lado, é vedada a concessão de sursis ou substituição por pena restritiva de direitos, pela ausência dos requisitos subjetivo e objetivo. Ressalto, quanto tal aspecto que, não obstante a decisão tomada no HC 97.256/RS, do STF, que não possui cunho vinculante, com a devida vênia, não se verifica compatibilidade lógica da pena restritiva com a natureza da infração, sendo que deveria a defesa fazer prova de que o Acusado possui condições da substituição da pena corporal, o que não é afastado nem mesmo diante da Resolução nº 5/2012 do Senado, não havendo que se falar em violação ao princípio da individualização da pena, porquanto esta deve se dar respeitando parâmetros preestabelecidos pela lei, notadamente porque o artigo 5º, inciso XLIII, da CF/88 determinou regime mais rigoroso na reprimenda de crimes

hediondos e equiparados.

Relevo, ainda, que a disposição do artigo 44 do Código Penal, que trata da conversão de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não é de aplicação automática, pois elenca os requisitos legais para tanto. Ali, em seu inciso III, estabelece que somente é aplicável a comutação quando a conduta social do réu, além dos motivos e circunstâncias do delito, forem favoráveis. A simples prática do narcotráfico, este o flagelo de nossa sociedade, indica o sujeito ativo do crime como pessoa portadora de péssima conduta social, sendo que os motivos e circunstâncias do crime são, evidentemente, desfavoráveis. Para isso, basta se ter contato com um usuário de entorpecente para se verificar a miséria que se tornou sua existência (e de sua família), tão-somente pelo consumo daquilo que é oferecido pelo traficante (ainda que seja um “pequeno” traficante).

Para o crime de narcotráfico, circunstâncias como primariedade, bons antecedentes ou emprego lícito (sendo que o Réu não é possuidor de nenhum destes predicados) servem para fixar a pena aplicada, bem como, quando o caso, o critério redutor. Contudo, não viabiliza a conversão em pena restritiva ou mesmo a fixação em regime que não o fechado, em vista dos diplomas legais acima citados, pois insuficiente à repressão e prevenção desta infração equiparada à crime delito hediondo. Nesse sentido, lapidar excerto de acórdão do E. Tribunal de Justiça Bandeirante, verbis: “Ressalta-se que a decisão apresentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 111.840/ES, em 27 de junho de 2012, reconhecendo e declarando incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90 tem seus efeitos 'restritos ao processo e às partes litigantes', não possuindo efeito 'erga omnes', até porque, não afastada pela Suprema Corte a natureza hedionda do delito de tráfico, justificando a imposição do regime mais gravoso, em respeito aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena. Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, possibilitando a imposição de regime fechado para o crime de tráfico de entorpecente: HABEAS CORPUS nº 189.960/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 16.08.2012; HABEAS CORPUS 216.265/SP. Rel. Min. Og Fernandes, DJe 02.06.2012; HABEAS CORPUS 199.619/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 27.08.2012; e HABEAS CORPUS nº 225.568/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe. 27.08.2012.

Não há que se falar em conversão da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, havendo a necessidade de pronunciar algumas considerações. Com efeito, o Senado, na forma do artigo 52, inciso X da Constituição Federal e com olhos voltados para o julgamento do HC nº 97.256/RS, pelo Supremo Tribunal Federal, editou a Resolução nº 05/2012, cujo teor é a suspensão da parte que obstaculizava a conversão da pena privativa de liberdade em pena alternativa, inserida no parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

No entanto, com a devida vênia, o traficante, seja de pequeno, de médio ou de grande porte, não tem mérito para inicialmente cumprir a pena cominada de outra forma que não encarcerado.

Em vista o postulado implícito da proporcionalidade (HUMBERTO ÁVILA, Teoria dos Princípios, Ed. Malheiros), que é uma espécie de norma jurídica derivada do devido, justo e adequado processo legal (FAIR TRAIL), não se mostra razoável que o traficante, condenado por delito equiparado a hediondo (artigo 5º, inciso XLIII da Constituição Federal) venha a receber tratamento similar ao agente que perpetra um delito de menor potencial ofensivo.

Nesse contexto, pondera-se: de onde viria o numerário para o traficante cumprir a prestação pecuniária? E mais: onde o traficante, disseminador de vício, cumpriria prestação de serviços à comunidade ou entidade pública? Nas escolas? Nas creches? Nos orfanatos? Nos abrigos? Nos hospitais?

Em suma, não se mostra adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito em casos de tráfico de entorpecente, uma vez que tal medida atenta contra a efetividade do processo penal na aplicação do justo concreto, atingindo frontalmente o caráter retributivo da reprimenda e a dimensão material ou

substancial do 'DUE PROCESS OF LAW'.

Além disso, é válido ressaltar que os recentes arestos do Colendo Superior Tribunal de Justiça indicam que não há ilegalidade na negativa de permuta, quando fundada na multiplicidade e na natureza lesiva das drogas apreendidas, isso porque a conversão da sanção reclusiva não seria suficiente para a prevenção e a repressão do delito denunciado (HC 204115 / MG - Ministro JORGE MUSSI - QUINTA TURMA - DJe 15/02/2012). E, na espécie, como foram apreendidas porções consideráveis de 'maconha', a aplicação de pena alternativa encontra óbice na exegese do artigo 44, inciso III, do Código Penal, sendo insuficiente como resposta à culpabilidade do agente, aos motivos e às consequências do exercício da atividade ilícita" (TJSP, Ap. 0005407-56.2011.8.26.0210, 4ª C.D.Crim., Rel. Des. Euvaldo Chaib, j. 18.12.2012).

Lado outro, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, porquanto o crime apurado é classificado como vago, assim entendido aquele que tem por sujeito passivo a sociedade, destacando, outrossim, que não se comprovou qualquer dano causado em sujeitos passivos secundários (pessoa submetida aos riscos da lesão).

À derradeira, tendo em vista que o Acusado foi condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo com ele localizado quantia em dinheiro, evidenciando-se seu emprego na venda de drogas ilícitas, bem como telefone celular que se mostrou utilizado na traficância, com fulcro no artigo 63, caput, do aludido diploma legal, decreto a perda do celular e dos valores apreendidos com o Réu, depositados em Juízo, que deverão ser encaminhados em favor da União, com o trânsito em julgado desta sentença (artigo 63, parágrafo 1º).

III. Isto posto e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e, em consequência, CONDENO o Réu APARECIDO DONISETI LEITE, qualificado nos autos, à pena de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1.000 (um mil) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, com correção monetária a partir do fato delituoso, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em regime inicial fechado, vedada a substituição por pena restritiva de direitos ou concessão de sursis. No mais, decreto a perda do dinheiro e do telefone celular apreendidos com ele, em favor da União.

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no Rol dos Culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) e encaminhem-se o numerário e telefone celular apreendidos em favor da União.

Diante da pena aplicada, em regime inicial fechado em razão da equiparação à hediondez, por seus péssimos antecedentes e ainda por sua multirreincidência, o Réu, descontente com a decisão, deverá aguardar o julgamento do recurso preso, mantendo, então, sua prisão cautelar, sem prejuízo da apelação, nos termos do artigo 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal, pois nada justifica que, preso em flagrante, fosse colocado em liberdade depois de condenado.

São devidas custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Guaira, 10 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA